

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제4절 변론>

I. 변론의 내용

1. 본안의 신청

(1) 의의

- 본안의 신청이란 당사자가 법원에 대하여 어떠한 내용의 판결을 구하는가를 명시하는 의사표시이다. 원고의 경우 소장에 기재된 청구취지를 진술함으로써 본안의 신청을 하며, 이는 심판의 대상과 범위를 확정하는 기초가 된다.

(2) 상대방의 태도 - 반대신청

- 피고는 원고의 본안 신청에 대응하여 '원고의 청구를 기각한다'라는 내용의 반대신청을 한다. 이는 원고의 청구가 이유 없음을 주장하며 자신에게 유리한 판결을 구하는 적극적인 소송행위이다.

2. 공격방어방법

(1) 의의

- 공격방어방법이란 당사자가 자신의 본안 신청을 뒷받침하기 위해 제출하는 일체의 소송자료를 의미한다. 원고가 청구를 근거 짓기 위해 제출하는 자료는 공격방법이라 하고, 피고가 청구를 배척하기 위해 제출하는 자료는 방어방법이라 한다. 사실의 주장, 법률적 견해의 개진, 증거의 신청 등이 이에 포함된다.

(2) 주장

- 당사자는 자신에게 유리한 법률효과를 발생시키는 기초 사실을 주장하여야 한다. 변론주의 원칙상 법원은 당사자가 주장하지 않은 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없으므로, 적절한 시기에 명확한 사실주장을 하는 것이 중요하다.

3. 증거신청

(1) 의의

- 증거신청이란 다툼이 있는 사실의 존부를 확정하기 위하여 법원에 증거조사를 요구하는 행위이다. 증인신문, 감정, 서증의 제출, 검증 신청 등이 대표적이다.

(2) 상대방의 태도

- 상대방은 증거신청에 대하여 증거능력이나 증거력을 다투거나, 반대증거를 신청함으로써 대응한다. 또한 서증의 경우 인부(인정·부인) 절차를 통해 해당 문서의 진정성립 여부를 밝히게 된다.

4. 항변

(1) 항변의 의의

- 항변이란 상대방의 주장 사실을 인정하면서도, 그 사실에 의한 법률효과를 배제하기 위해 별개의 사실을 주장하는 방어방법이다.

(2) 소송상의 항변

- 본안 판결을 막기 위해 소송요건의 흠결을 주장하는 것이다. 관할 위반의 항변, 중복소제기의 항변 등이 이에 해당하며, 이는 소송판결을 구하는 방어수단이다.

(3) 본안의 항변

- 원고의 청구가 실체법상 이유 없게 만드는 사실을 주장하는 것이다. 소멸시효의 완성, 변제, 상계, 정지조건의 미성취 등이 전형적인 본안의 항변이다.

5. 부인과 항변의 구별

(1) 부인과 항변의 의의

- 부인이란 상대방이 주장하는 사실 자체를 부정하는 것이고, 항변은 상대방의 사실은 인정하되 새로운 사실을 추가하여 효과를 뒤집는 것이다.

(2) 부인과 항변의 구별

- 부인은 상대방이 주장하는 사실의 부존재를 주장하는 것이므로 증명책임이 상대방(원고)에게 그대로 남는다. 반면, 항변은 새로운 사실을 도입하는 것이므로 그 항변 사실에 대한 증명책임은 항변자(피고)가 부담한다.

(3) 간접부인과 항변의 구별

- 간접부인이란 상대방의 주장 사실과 양립할 수 없는 별개의 사실을 주장함으로써 결과적으로 상대방의 주장을 부정하는 것이다. 이는 사실의 부정이라는 점에서 부인의 일종이며, 증명책임이 전환되지 않는다는 점에서 항변과 구별된다.

(4) 구별의 실익

- 가장 큰 실익은 증명책임의 소재에 있다. 당사자의 주장이 부인인지 항변인지에 따라 어느 쪽이 입증에 실패했을 때 불이익을 받을지가 결정되기 때문이다.

6. 소송상 형성권의 행사

(1) 의의

- 소송 계속 중에 상계, 해제, 취소와 같은 실체법상 형성권을 행사하는 것을 의미한다.

(2) 학설

- 사법행위설(실체법상 효과 중시), 소송행위설(소송절차 내의 효과 중시), 병존설(양 성질을 모두 가짐) 등이 대립한다.

(3) 판례

- 판례는 원칙적으로 소송상 형성권 행사를 사법상 행위와 소송행위가 결합된 형태로 보며, 소송이 취하되거나 각하되면 형성권 행사의 실체법적 효과도 소멸한다고 보는 병존설 중 소송적 효과를 중시하는 입장에 가깝다.

(4) 검토

- 절차의 안정성과 실체적 정의를 조화시키기 위해서는 소송상 형성권 행사의 운명을 소송 절차의 운명과 결합시키는 것이 타당하다.

7. 상계항변에 대한 재항변의 가부

(1) 문제점

- 피고가 상계의 항변을 했을 때, 원고가 다시 그 자동채권에 대해 소멸시효 완성 등의 사유로 재항변을 할 수 있는지가 문제된다.

(2) 소송상 상계의 재항변 허용 여부

- 판례는 원고가 피고의 자동채권에 대하여 별도의 채권을 가지고 다시 상계하는 상계의 재항변은 원칙적으로 금지한다. 이는 심리를 지나치게 복잡하게 하고 중복제소의 위험이 있기 때문이다. 다만, 피고의 자동채권이 이미 소멸했다는 등의 일반적인 재항변은 당연히 허용된다.

II. 소송행위

1. 소송행위의 의의

- 소송행위란 소송절차를 구성하고 판결의 기초가 되는 효과를 발생시키는 법원과 당사자의 행위를 말한다. 주로 당사자의 행위를 지칭하며, 실체법상의 법률행위와 달리 절차적 확실성을 강조한다.

2. 소송상 합의★

(1) 소송상 합의의 의의

- 당사자 간의 합의로 소송법상의 효과를 발생시키는 것을 말한다.

(2) 소송상 합의의 허용 여부

- 강행법규에 반하지 않는 범위 내에서 허용된다. 관할 합의, 상소권 포기 합의 등은 법률이 명시적으로 허용하고 있다.

(3) 소송상 합의의 방식

- 원칙적으로 명시적이어야 하며, 법원에 제출된 서면이나 변론조서에 기재됨으로써 효력이 발생한다.

(4) 소송상 합의가 미치는 범위

- 합의의 당사자뿐만 아니라 그 승계인에게도 효력이 미치는 경우가 많다. 다만, 제3자의 절차적 권리를 침해하는 합의는 무효이다.

(5) 개별적 검토

- 부제소 특약(소를 제기하지 않기로 하는 합의)은 특정 법률관계에 한정되고 당사자가 처분할 수 있는 권리라면 유효하다.

3. 소송행위의 의사표시의 하자과 철회

(1) 의사표시의 하자과 소송행위의 취소

- 실체법상의 착오, 사기, 강박에 의한 취소 규정은 소송행위에 원칙적으로 적용되지 않는다. 소송절차의 외관과 안정성을 중시하기 때문이다. 다만, 형사상 처벌받을 타인의 행위로 인한 경우 등 극히 예외적인 경우에만 취소가 인정된다.

(2) 소송행위의 철회의 자유

- 소송행위는 상대방에게 기득권이 생기기 전이나 법원의 판단이 내려지기 전까지는 원칙적으로 철회할 수 있다. 예를 들어 자백의 경우 상대방의 동의가 있거나 착오에 의한 것임을 증명하면 철회가 가능하다.

(3) 소송행위의 효력을 다투는 방법

- 소송행위의 무효나 취소는 당해 소송절차 내에서 주장하여야 하며, 별개의 소로써 다투는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

4. 소송행위의 하자과 치유

(1) 소송행위의 하자

- 방식의 위배, 대리권의 흠결, 기간의 도과 등이 소송행위의 하자가 된다.

(2) 하자의 치유

- 무효인 소송행위라 하더라도 사후에 추인하거나, 상대방이 책문권을 상실(이의를 제기하지 않음)함으로써 유효하게 될 수 있다. 특히 임의규정 위반의 경우 책문권 상실에 의한 하자 치유가 빈번하게 일어난다.

III. 결론

- 변론은 당사자의 주장과 방어수단이 격돌하는 동적인 과정이며, 그 안에서 행해지는 소송행위들은 실체법과는 다른 독자적인 논리에 의해 지배된다. 부인과 항변의 정확한 구별은 증명책임의 분배를 결정짓는 핵심이며, 소송상 형성권 행사는 사법적 권리와 소송적 절차의 접점을 보여준다. 법원은 소송행위의 하자를 엄격히 관리하면서도 당사자의 진정한 의사가 재판에 반영될 수 있도록 석명권을 행사하고 절차를 유연하게 운영하여야 한다. 특히, 소송절차의 안정성을 위해 소송행위의 철회나 취소를 제한하는 법리는 당사자의 절차적 기본권과 충돌할 수 있으므로, 구체적 사안에서 형평에 맞는 세밀한 해석이 요구된다.